

1510992-31.2020.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203435/2020 - DEL.POL.ARARAS, 13067553 - DEL.POL.ARARAS, 2671/20/805 - DEL.POL.ARARAS, 2203435 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510992-31.2020.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510992-31.2020.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203435/2020 - DEL.POL.ARARAS, 13067553 - DEL.POL.ARARAS, 2671/20/805 - DEL.POL.ARARAS, 2203435 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face dos acusados LUIZ HENRIQUE DA SILVA, JÉSSICA FERNANDA VILELA, RODRIGO FELIPE CÉSAR e ALAN MATHEUS MARQUEZINI, já qualificados nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 18 de agosto de 2020, por volta 21h50min, na Avenida João Buzzo, nas proximidades do Condomínio Victorio Corrocher, Jardim Sobradinho, na cidade de Araras, os réus Luiz Henrique da Silva e Jéssica Fernanda Vilela, agindo em concurso, transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, em peso bruto, 89g (oitenta e nove gramas) da droga conhecida como maconha, em quarenta e duas porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, no dia 18 de agosto de 2020, por volta 21h50min, na Avenida João Buzzo, nas proximidades do Condomínio Victorio Corrocher, Jardim Sobradinho, na cidade de Araras, o réu Rodrigo Felipe, conhecido por "Cenoura" e o réu Alan Matheus, agindo com comunhão de esforços e unidade de desígnios, transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, em peso bruto, 67g (sessenta e sete gramas) de cocaína, em quarenta e cinco flaconetes; 7g (sete grama) de droga conhecida como crack, em quarenta e oito porções em formato de "pedra" e 28g (vinte e oito gramas) de droga conhecida como maconha, em dez porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que no dia 18 de agosto de 2020, após as 21h50min, Rua Wadih Georges Hoche, nº 154, Parque Tiradentes, na cidade de Araras, os réus Luiz Henrique e Jéssica Fernanda, agindo em concurso, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, em peso bruto, 75g (setenta e cinco gramas) de droga conhecida como maconha, em vinte e nove porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados (fls. 201, 232, 234 e 237) e apresentaram as respectivas defesas preliminares (fls. 206/212 e 253/255).

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 262/263). Os acusados foram citados (fls. 283, 342, 344 e 353).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas (fls. 365, 500 e 501), sendo os acusados interrogados (fls. 502, 503, 505 e 595).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 599/611- MP, 616/618 - Rodrigo e Alan e 622/638 - Luiz e Jéssica). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação dos acusados, nos termos da denúncia. A defesa pleiteou, em suma, a absolvição dos réus.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A absolvição é de rigor. Vejamos:

Interrogado em juízo, o réu Luiz Henrique da Silva admitiu possuir drogas, quando abordado, para consumo pessoal. Admite ainda a apreensão de drogas em sua casa, as quais também eram para seu consumo (fls. 502).

A ré Jéssica Fernanda Vilela disse ter sido abordado juntamente com Luiz Henrique, seu marido. Admite que portava 680 reais referente ao auxílio emergencial. Informou que Luiz é usuário de maconha. Negou ter autorizado o ingresso de guardas municipais em sua casa. O dinheiro localizado no imóvel era relativo a venda de veículo (fls. 503).

O acusado Rodrigo Felipe César também negou a prática delitiva. Disse, em síntese, que guardas municipais ingressaram em sua casa pela janela e abordaram seu irmão Alan. Outro guarda entrou pela porta, estourando-a. No imóvel havia "pinos" do seu irmão. O veículo Corsa é de propriedade de sua genitora e estava na garagem de um vizinho (fls. 595).

De igual maneira, o denunciado Alan Matheus Marquezini disse estar deitado quando os guardas invadiram o imóvel. Alega que havia apenas drogas para seu consumo pessoal. O veículo apreendido é de seu irmão, o corréu. Não estavam dentro do carro quando da abordagem (fls. 505).

De outro lado, os guardas municipais disseram ter recebido delação anônima sobre o

abastecimento de ponto de tráfico do "Cenoura" (réu Rodrigo) por pessoas num veículo Fiesta Preto. Em patrulhamento nas imediações da "biqueira" avistaram referido veículo e fizeram a abordagem logrando apreender 42 porções de maconha e 680 reais com os réus Luiz Henrique e Jéssica. Ato contínuo, dirigiram-se à referida "biqueira", onde avistaram os corréus Alan e Rodrigo dentro de um veículo Corsa. Ambos, ao notarem que seriam abordados, empreenderam fuga a pé e jogaram um estojo preto, dentro do qual localizaram porções de maconha, cocaína e crack. Os acusados referidos foram detidos dentro do apartamento usado como ponto de tráfico. Já na Delegacia, ouviram Jéssica comentar como os demais detidos sobre a existência de drogas em sua casa. Indagada, Jéssica teria autorizado o ingresso dos servidores municipais no imóvel, onde mais drogas (maconha) e dinheiro foram apreendidos.

Arline de Araújo Gomes, mãe do réu Luiz Henrique e ouvida na qualidade de informante, não presenciou os fatos, afirmando que seu filho é usuário de maconha.

São as provas dos autos.

A absolvição é de rigor.

Não se nega aqui a possibilidade de prisões em flagrante feitas por guardas municipais. Entretanto, no caso, diversas ilegalidades foram cometidas.

A par da nítida atividade investigativa empreendida pelos agentes do Município, o que, por si só, invalidaria toda a ação estatal e as provas delas decorrentes, tem-se que a abordagem do veículo ocupado por Jéssica e Luiz Henrique, e posterior revista pessoal e veicular, teve como base exclusivamente denúncia anônima, o que é vedado por nosso ordenamento ante a ausência de justa causa.

O mesmo se diga em relação a abordagem dos corréus Alan e Rodrigo perseguidos e abordados com fulcro em mencionada delação e pelo fato de correrem ao notar a chegada dos guardas, o que também, como se verá a seguir, não autoriza a revista pessoal, conforme entendimento de nossos Tribunais, em especial o E. STJ.

Não bastasse isso, invadiram casas sem mandado, sem prova de que tenha havido autorização dos moradores e sem situação de certeza visual da flagrância delitiva, ou seja, sem justa causa para tanto.

O fato de terem sido encontrada e apreendida quantidade considerável de drogas não é suficiente para convalidar os vícios de origem da ação dos guardas municipais, que agiram fora de suas atribuições legais.

Vejamos:

Conforme ensina o mestre E. Magalhães Noronha, "A casa é o asilo inviolável do cidadão"; os ingleses dizem 'My house is my kingdom' (Minha casa é meu reino)." (Curso de Direito Processual Penal, 5a. Edição, editora Saraiva, 1972, p. 93)

Por ser a casa local inviolável, e sendo, porém, permitido o ingresso em situação de flagrância delitiva, a Corte Suprema andou bem ao deliberar, com repercussão geral (Tema 280) quando permitido ingresso por autoridades estatais sem mandado judicial, coibindo-se ações arbitrárias, a saber:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Em complementação, o E. STJ entende que "As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do

suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente." (STJ, 6a. Turma, HC 598.051 - SP, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, em 02 de março de 2021).

Assim sendo, tem-se que, no caso em apreço, o ingresso domiciliar sem mandado ESTÁ eivado de nulidade.

Isso porque, como dito acima, denúncias anônimas não são justificadoras de grave e sério restrição ao direito de inviolabilidade domiciliar. Nesse sentido:

"(...) No caso em tela, os policiais deram ordem de parada aos corréus em razão de denúncias anônimas que afirmavam estar sendo realizado tráfico de drogas na região. Dado que o motociclista avançou e o carona dispensou um invólucro com 83g (oitenta e três gramas) de insumos para preparo de cocaína, os agentes foram detidos e todos se deslocaram à residência de um deles, onde foram encontrados mais 19g (dezenove gramas) dos mesmos insumos..3. Portanto, de plano, há ilegalidade na abordagem e revista pessoal nos agentes em razão de terem como lastro somente denúncias anônimas não registradas e não sindicáveis, com o posterior ingresso forçado em domicílio fora das hipóteses legais." (STJ, 6ª. Turma, HC 696390/SP, de relatoria do Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgamento em 20/09/2022).

"(...) No caso em tela, os agentes policiais, após receberem denúncia anônima, deslocaram-se ao local indicado e abordaram o ora paciente, não encontrando nada de ilícito, mas ainda assim se dirigiram à sua casa, onde encontraram 198g (cento e noventa e oito gramas) de cocaína, bem como mensagens de mercancia de drogas em seu celular. 3. A violação de domicílio teve como justificativa, como visto acima, tão somente denúncia anônima, tanto que nada de ilícito foi encontrado com o agente quando da revista pessoal, circunstâncias fáticas que não autorizam a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência nem a devassa em suas mensagens de celular, acarretando a nulidade da diligência policial, porquanto não há detalhamento acerca da apreensão precedente. (...) "(HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior, 6ª. Turma, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)." (STJ, 6ª. Turma, HC 734326/PR, de relatoria do Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgamento em 20/09/2022). - grifos nossos

E mais, em relação ao denunciados Alan e Rodrigo, nem mesmo o fato de empreenderem fuga é capaz de justificar o ingresso ilegal em domicílio alheio,"ex vi":

"A violação de domicílio com base no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga ao ver a viatura policial, não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência." (HC 695.980-GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

Ainda em relação à abusividade do ingresso domiciliar no caso vertente, é de se ressaltar que suposta autorização dada Jéssica, além de inverossímil, não está demonstrada nos autos, devendo ser desconsiderada.

Efetivamente, contraria o bom senso a afirmação dos guardas de que teria ela autorizado o ingresso em sua casa mesmo sabendo que ali havia drogas.

Além disso, referida autorização deveria ser confirmada pelo Estado por outros elementos, o que não ocorreu.

A simples afirmação dos policiais no sentido de que tiveram autorização do morador,

sem que seja por ele confirmada em juízo e/ou perante a autoridade policial (ou por outro elemento idôneo, tal qual gravação ou autorização por escrito), não pode ser considerada válida.

Nesse sentido:

“(...) A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor (...)” (STJ, 6a. Turma, HC 598.051 - SP, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, em 02 de março de 2021).

Havendo controvérsia acerca da existência da autorização, cabe ao Estado provar sua existência, sob pena de ser tida como ilegal:

“Tráfico de drogas Controvérsia sobre a existência de autorização para ingresso na residência Recente posicionamento do STJ no sentido de que cabe ao Estado comprovar a autorização Prova, nestes autos, inexistente, sendo que a dúvida deve favorecer a Defesa Obtenção de parte da prova por meios ilícitos Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio Reconhecida a ilicitude da apreensão dos entorpecentes encontrados na residência do acusado Desconsideração de tais provas para o exame da conduta do réu Remanesce o fato de ter sido abordado, em via pública, com 2,2g de crack Inexistência de comprovação do intuito de comercialização Desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal Aplicada pena de advertência sobre os efeitos das drogas” (TJSP, 12a Câmara de Dir Criminal, Apelação Criminal nº 1501121-45.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria Des. Amable Lopez Soto, em 08 de julho de 2022). – grifos nossos.

No caso acima mencionado, restou assim consignado pelo Exmo Des. Relator,

“(...) Aqui, como visto, no que toca ao ingresso dos policiais no imóvel referido na denúncia, há controvérsia que a prova não resolve com o necessário critério de certeza.

Dúvida que não pode ser resolvida com base na afirmação de que depoimento de policial goza de presunção de idoneidade a ponto de preponderar sobre a prova de defesa.

In casu, a dúvida quanto à dinâmica dos fatos não pode ser resolvida a favor da Acusação. Pelo contrário. Se o Ministério Público não logra demonstrar de forma inequívoca a legalidade do ingresso de policiais na casa de quem quer que seja, a diligência deve ser declarada ilícita. A dúvida, como cediço, deve favorecer o réu. (...)”

Resta, assim, evidente ser ônus do Estado a demonstração de que houve prévia autorização para ingresso na residência, que não pode ser admitida válida simplesmente com os depoimentos dos agentes estatais envolvidos na ocorrência.

Nesse sentido, o E. STJ

“(...) BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL (...)” (STJ, HC 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a. Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021)

"Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa

autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior, 6ª. Turma, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Superado o tema relativo ingresso domiciliar, voltemos ao da ilegalidade da revista pessoal sem a presença de justa causa.

Conforme prevê o art. 240, §2º, do CPP: "Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior."

Desta feita, requisito imprescindível à legalidade do ato é a existência de fundada suspeita.

Não podem, os agentes estatais realizarem abordagens indistintas, sem que haja algo de concreto, de palpável, a justificar a abordagem de cidadãos, sob pena de violação do princípio da dignidade humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88).

Além disso, ainda quando justificada a abordagem e busca pessoal, deverá a autoridade estatal abster-se de proceder de forma vexatória, desumana ou degradante (art. 5º, III, da CF/88).

Com efeito, exigir-se a existência, ainda que mínima, de indícios de cometimento de algo ilícito (justa causa) é pressuposto necessário para garantia de direitos fundamentais do indivíduo, tais como aqueles previstos no Pacto de São José, em seus artigos 5º e 11, a saber: direito a integridade física, psíquica e moral; de não sofrer tratamento degradante e de ser tratada com o devido respeito à dignidade inerente ao ser humano, pois "toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade" (art. 11, item 1)

Ninguém olvida que abordagens e revistas policiais configuram, no mais das vezes (e as máximas de experiência apontam nesse sentido), situação de constrangimento, razão pela qual não podem ser aceitas com se lícitas fossem sem que haja substrato fático apto a justificá-las em prol da coletividade, sob pena de ilegalidade.

Assim sendo, resta indubitável que os agentes estatais, balizados que são pelas normas legais, até porque vivemos em Estado de direito, não são livres para revistarem pessoas "a torto e a direito"

Indubitável, porém, que a análise do conceito de "fundada suspeita" comporta certa carga de subjetividade.

De qualquer, conforme adverte o doutrinador Paulo Rangel, "quando a lei se refere a fundadas razões exige que haja um fato concreto autorizador da formação da suspeita. A busca somente será legítima se, efetivamente, houver um dado objetivo, um dado concreto, um fato d avida que autoriza os agentes realizarem a busca e apreensão. O simples olhar do policial, entendendo tratar-se de um carro suspeito ou de uma pessoa suspeita, por exemplo, não pode autorizar a busca a apreensão, sem que haja um dado objetivo impulsionando sua conduta" (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal, 20a. Edição, editora Atlas, 2012. P. 150).

E mais, continua o nobre autor: "Tornaghi ensina-nos que as fundadas razões que autorizam a busca devem estar lastreadas em indícios fortes de que a pessoa ou coisa procurada encontra-se no lugar da busca" (idem, p. 151)

Buscas realizadas a esmo não são autorizadas por lei. Logo, ilícitas devem ser declaradas.

Nessa linha de entendimento, o E. STJ assim deliberou:

"(...) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (...) O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (...) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial." (STJ, RHC 158580/BA, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz – grifos nossos).

E mais, "O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida" (STJ, RHC 158580/BA, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz – grifos nossos).

E ainda deve mesmo ser para: "evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;" bem como para "evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural." (STJ, RHC 158580/BA, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz).

Isso poque: "A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente constroem os famigerados "elementos suspeitos" com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela." (STJ, RHC 158580/BA, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz)

No caso concreto, a abordagem e revista inicial em Luiz e Jéssica é ilegal, eis que baseada exclusivamente em delação apócrifa.

Nesse diapasão:

"Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª. Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

Da mesma forma, em relação a Rodrigo e Alan, a abordagem se fundou apenas no fato de estarem em atitude suspeita (contando dinheiro) e por terem fugido, o que também, nos moldes das decisões abaixo transcritas, não são capazes de justificar o Estado de intervir na liberdade individual.

“(...) No caso em tela, os policiais avistaram o recorrente "em atitude suspeita", o que motivou a abordagem e a busca pessoal, ocasião em que encontraram pequena quantidade de drogas. Daí deslocaram-se até a residência do agente, onde, alegadamente, obtiveram autorização da proprietária do imóvel para o ingresso no domicílio, no qual foram encontradas as demais drogas. 4. Portanto, de plano, há ilegalidade na abordagem e revista pessoal nos agentes em razão de terem como lastro somente a atividade suspeita do agente, com o posterior ingresso forçado em domicílio fora das hipóteses legais. (...)” (STJ, 6ª. Turma, Resp 2018394/GO, de relatoria do Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgamento me 20/09/2022).

“(...) 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. Verifica-se dos autos que os "guardas municipais realizavam ronda quando se depararam com o acusado, que correu assim que os viu, fato que levantou suspeita e motivou a abordagem". Foi então realizada a abordagem do acusado em local público, e, na busca pessoal, foi localizada em seu poder "uma sacola que continha 60 porções de maconha e 58 de cocaína (...) 4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, e mesmo pela falta de atribuições dos guardas municipais para a busca, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia. (...)” (STJ, 6ª. Turma, HC 704964/SP, de relatoria do Min. Olindo Menezes, julgamento em 09/08/2022).

Por fim, para finalizar a série de ilegalidades, constata-se nos autos nítida e irrefutável atividade investigativa exercida por guardas municipais que, após receberem delação anônima, abordaram e revistaram Jéssica e Luiz (ilegalmente) para, ato contínuo, deslocarem-se a suposta biqueira e também (ilegalmente) abordarem os réus Alan e Rodrigo, dentro de imóvel para o qual não tinham autorização judicial ou dos moradores ou mesmo justa causa para ingressarem. Não satisfeitos, invadiram (sem prova da alegada autorização) a casa de Luiz e Jéssica.

Resta, assim, evidente que os guardas, ainda que de boa-fé, extrapolaram suas funções, exercendo verdadeira atividade investigativa e ostensiva, de incumbência respectiva da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Nesse sentido, recorro que “Por Estado de direito entende-se geralmente um Estado em que os poderes públicos são regulados por normas gerais (as leis fundamentais ou constitucionais) e devem ser exercidos no âmbito das leis que os regulam, salvo o direito do cidadão de recorrer a um juiz independente para fazer com que seja reconhecido e refutado o abuso ou excesso de poder” (BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia, tradução: Marco Aurelio Nogueira. Editora brasiliense, 1988, p. 18)

Ou seja, permitir-se a ação estatal ao arrepio da lei importaria negar-se a afirmação primeira de nossa Constituição Federal, qual seja, de que “A República Federativa do Brasil (...) constituiu-se em Estado Democrático de Direito” (art. 1º. “caput, da CF/88).

E mais, nunca é inoportuno repisar que Guarda Municipal não é Polícia.

Inclusive, nessa linha de constatação, o Egrégio Tribunal Paulista, ao julgar a ADIN no. 2272391-03.2021.8.26.0000 (em 17 de agosto de 2022), refutou a possibilidade de alteração de referida instituição para “Polícia Municipal”, “in

verbis”:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.DECRETO AUTÔNOMO. ALTERAÇÃO DADENOMINAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPALPARA POLÍCIA MUNICIPAL. Normas constitucionais referentes à segurança pública que são de observância obrigatória pelos entes estatais subnacionais. Guarda municipal que não integra o rol das instituições responsáveis pela segurança pública no Brasil (caput do artigo 144 da Constituição Federal). Guardas municipais às quais se conferiu apenas a função de proteger bens, serviços e instalações municipais, obedecidos os preceitos da lei federal (§ 8º do artigo 144 da Constituição Federal e artigo 147 da Constituição Estadual). Inconstitucionalidade configurada.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2272391-03.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo). – grifos nossos

Desta feita, a atuação dos guardas como se policiais fosse afronta o disposto no artigo 144, §8º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Com efeito, o art. 144, da CF/1988 é claro ao atribuir o policiamento ostensivo exclusivamente à Polícia Militar e a função investigativa compete à Polícia Civil, facultando aos Municípios a criação de Guardas Civis para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Como dito, não se desconhece que qualquer do povo pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como acima já disposto e como disciplina o Código de Processo Penal, em seu artigo 301.

Assim, patente a ilegalidade da ação dos guardas civis municipais.

Nem mesmo a Lei Federal de nº 13.022/2014, que estabeleceu as competências das Guardas Municipais, autoriza as guardas exerçam atividades típicas da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Nesse sentido, em ação direta de inconstitucionalidade de nº 154.743-0/0-00 (autos nº 9039481-58.2007.8.26.0000), o E. Tribunal Paulista deliberou que:

“(...) A faculdade outorgada aos municípios de criação de suas guardas não lhes concede o direito de extrapolar os limites ali impostos, ou seja, visam unicamente a proteção de seus bens, serviços e instalações, devendo ser repelida qualquer tentativa de alargamento desse horizonte, quando mais se constatada invasão a outras esferas.”

Em Recurso Extraordinário (nº 608.588/SP), ainda pendente de julgamento, contra mencionado “decisum”, o ilustre Procurador-Geral da República, asseverou que:

"Estão fora das atribuições constitucionais das guardas municipais as atividades que extrapolem a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, como as de policiamento ostensivo fora desse contexto, as de polícia judiciária e a apuração de infrações penais".

Desta feita, atento ao princípio da legalidade estrita, aplicável aos agentes estatais, bem como ao disposto no §8º, do art. 144, da CF/1988, concluo pela ilegalidade na atuação dos guardas municipais no caso presente.

A orientação recente de nossos Tribunais aponta nessa exata direção. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste óbice à prisão em situação de flagrância, efetivada por guardas municipais ou qualquer outra pessoa, não havendo falar, em tais casos, em ilicitude das provas daí decorrentes. 2. Na hipótese, entretanto, após denúncia anônima, guardas municipais

abordaram o réu e, com ele não encontrando entorpecentes, seguiram até terreno localizado nas proximidades, onde foram apreendidos, além de maconha, 10 reais, um filme plástico utilizado para embalar a droga e documento relativo à execução criminal do réu. 3. Desempenhada atividade de investigação, deflagrada mediante denúncia anônima, que desborda da situação de flagrância, deve ser mantido o reconhecimento da invalidade das provas dela decorrentes. 4. Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 1854065/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

No mesmo diapasão, a Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal do E. TJSP já deliberou:

“Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Impetração que espera o trancamento da ação penal com base na nulidade da prova. Busca e apreensão realizada por Guardas Municipais. Ausência de justa causa. Ordem concedida.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2016545-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)

“HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação penal. Possibilidade em relação ao paciente. Drogas apreendidas por guardas civis municipais, no interior de residência, após atos de investigação, o que só seria cabível por agentes da Polícia Judiciária. Atuação dos agentes municipais que não encontra respaldo no artigo 144, §8º, da CF e na Lei n. 13.022/2014. Ilícitude da prova evidenciada. Ordem concedida.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2207704-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020)

Em suma, evidenciada a ilicitude da conduta dos guardas municipais, impõe-se o reconhecimento da invalidade das provas produzidas contra os denunciados, ensejando a absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER os réus LUIZ HENRIQUE DA SILVA, JÉSSICA FERNANDA VILELA, RODRIGO FELIPE CÉSAR e ALAN MATHEUS MARQUEZINI, já qualificados nos autos, da acusação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos nos autos, bem como a devolução do numerário e veículos apreendidos, estes com urgência e independentemente de trânsito em julgado, na qualidade de depositários, independentemente de pagamento de taxas. Oficie-se.

Autorizo também a devolução do aparelho de telefonia celular apreendido, cabendo à autoridade policial providenciar o necessário, mediante posterior comunicação a este juízo. Providencie-se o necessário.

Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão. Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I. Araras, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA